

1501434-13.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... da abordagem, conhecido como ponto de tráfico (Biqueira da Cachoeira), além do dinheiro apreendido, trazem elementos suficientes de que o réu tinha as drogas para entrega a terceiros.

Dessa forma, entende-se que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501434-13.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501434-13.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETERSON APARECIDO RIBEIRO DE SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

PETERSON APARECIDO RIBEIRO DE SOUZA foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 27 de julho de 2022, por volta das 09h29min, na Rua Cássia Imperial, 1, Jardim Quarto Centenário, nesta cidade de Mauá, o acusado possuía, expunha à venda, vendia e guardava, para fins de tráfico, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, descritas no auto de exibição e apreensão (fls. 13-4), laudo de constatação (fls. 16-20) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 78-81).

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 110) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa busca a absolvição ante a insuficiência de provas ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se a atenuante da confissão e a causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06, sob regime penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 08-11), auto de exibição e apreensão (fls. 13-4), laudo de constatação (fls. 16-20), fotografias de fls. 21-6, laudo de exame químico-toxicológico (fls. 78-81), laudo pericial do pote apreendido (fls. 82-5) e prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

O réu foi devidamente interrogado em solo policial e sob o contraditório (fls. 07 e mídia digital).

Os policiais civis, na fase administrativa, historiaram que (sic) "rumaram até a Rua Cássio Imperial – Invasão – Jd. IV Centenário - Mauá/SP, conhecido como BIQUEIRA DA COCHEIRA; Que, abordo de viatura descaracterizada, estacionaram em um ponto estratégico, aproximadamente 100 metros, com uso de binóculos, observaram a movimentação típica de tráfico de drogas, onde possíveis usuários de drogas entraram e uma rua que dá acesso a uma invasão e saíam rapidamente, sendo assim, após visualizarem aproximadamente cinco usuários, adentraram com a referida viatura na rua que dá acesso a invasão, quando viram um indivíduo desconhecido, de cor preta, o qual estava postado em pé junto a um muro de uma residência, com uma pequena bolsa de cor preta nas mãos, o qual não percebeu a aproximação do depoente e de seu parceiro; Que, abordado, não ofereceu qualquer resistência e assumiu que estava realizando o tráfico de drogas, sendo identificado como Peterson Aparecido Ribeiro de Souza, sendo que disse estar ali desde as 06:00 horas e ali ficaria até as 18:00 horas, e receberia 7% do total das drogas vendidas; Que, em revista pessoal a que foi submetido ainda no local dos fatos, nada de ilícito foi localizado em suas vestes, contudo, em um dos seus bolsos havia a quantia de R\$ 75,00, os quais segundo o detido eram oriundos da venda dos entorpecentes; Que, no interior do estojo de cor preta que trazia consigo, foram localizadas 27 invólucros de substância esverdeada, análoga a maconha; 24 papелotes plásticos contendo substância esbranquiçada, análoga a cocaína, 21 microtubos plásticos translúcidos com substância amarelada análoga a crack; e 3 tubos translúcidos com fragmentos esverdeados ressequidos, análogos a skank; Que, ainda pelo local dos fatos, em conversa informal com o detido, este relatou que havia nas proximidades, sob alguns entulhos nas proximidades, mais drogas escondidas, as quais serviriam para reabastecimento do ponto de vendas, desta forma, passaram a vasculhar as proximidades do local de venda, vindo a localizar sob uns pedaços de telhas de amianto, um sacola plástica de cor amarela, a qual continha em seu interior um pote plástico translúcido o qual visivelmente continha drogas em seu interior, sendo

localizados 15 invólucros plásticos contendo substância análoga a maconha, 28 invólucros plásticos contendo substância análoga a cocaína, 67 microtubos com substância análoga a crack, 3 tubos verde com substância ressequida análoga a skank e 2 invólucros plásticos com substância análoga a haxixe; Que, por esse motivo, lhe deram "voz de prisão", tendo sido conduzido às dependências desta distrital" (fls. 03-6).

Em juízo, o policial civil Sérgio reiterou integralmente a dinâmica do ocorrido (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

A versão dos policiais foi corroborada pelas fotografias juntadas às fls. 21-6.

Assim, a quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico (Biqueira da Cachoeira), além do dinheiro apreendido, trazem elementos suficientes de que o réu tinha as drogas para entrega a terceiros.

Dessa forma, entende-se que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base 1/5 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes (certidão de fl. 54 – proc. 1500386-53.2021) e da elevada quantidade de drogas apreendidas – 88 porções de crack (12,4g), 52 de cocaína (44,7g), 40 de maconha (33,9g), 06 de skunk (0,7g), além de 02 de haxixe (0,12g), fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e "crack" apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que

se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Ainda, quanto à possibilidade de utilização de uma das condenações, transitada em julgado, como maus antecedentes:

"Admite-se a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem". (STJ. REsp 1946490/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

"(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma." (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

"Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena." (HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

Na segunda etapa, aumento a reprimenda do réu em mais 1/3, diante da bi-reincidência específica (certidão fls. 50-1- procs. 394-80.2016 e 451-98.2016), totalizando 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Sobre a possibilidade de majoração da pena em patamar maior devido à dupla reincidência específica:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DA LEI 8.069/90. ART. 14 DA LEI 10.826/03 (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. (2) CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. (3) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ. PATAMAR FIXADO EM 1/3. AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. (4) CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DUPLA REINCIDÊNCIA GENÉRICA. QUANTUM DE ACRÉSCIMO IDÊNTICO AO DA DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA (5) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. Não é possível realizar a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando se tratar de reincidência específica. 3. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. No caso, em relação aos delitos de roubo circunstanciado, o acréscimo da pena pela reincidência se deu em 1/3 (um terço), aumento que não se mostra desarrazoado, tendo em vista escorreita valoração dada diante da dupla reincidência específica do paciente. 4. A fixação de idêntico patamar de aumento de pena na valoração da dupla reincidência genérica - delitos de corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido-, e da dupla reincidência específica - referente ao delito de roubo circunstanciado-, viola o princípio da proporcionalidade, porquanto sopesa de maneira equivalente circunstâncias desiguais. In casu, o Tribunal de Justiça reduziu a fração de aumento em relação à dupla reincidência específica (delito de roubo circunstanciado) de 3/8 (três

oitavos) para 1/3 (um terço), mantendo idêntico acréscimo em relação aos demais delitos, nos quais reincidência do paciente se dava de forma genérica. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda imposta ao paciente para 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ, HC 333531 / RJ, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 20/10/2015).g.n.

"Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a dupla reincidência específica do apelante, já tendo sido antes condenado definitivamente outras duas vezes pela prática de delito idêntico, conforme se infere de fls. 95/96 (Processos nº 0000780-09.2017.8.26.0142 e 0000351-76.2016.8.26.0142), suas reprimendas foram acertadas e novamente agravadas em 1/3." (TJSP, AP nº 1500200- 94.2020.8.26.0142, Des. Rel. Marco Antônio Cogan, j. 24.02.21).g.n.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante em plena traficância, em ponto de tráfico e na posse dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisor sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra: 'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é *contradictio in terminis*, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022).g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo

magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechados mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"(...) Não era o caso, outrossim, do reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto tenha ela sido parcial (negou o apelante o emprego de arma de fogo), bem como por ser ela refratária à prisão em flagrante. Como bem destacou o MM. Juízo a quo, no decurso, "(...) Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após desembarcar do veículo roubado, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos." (fls. 148). De mais a mais, ainda que fosse possível seu reconhecimento, nenhuma redução seria feita, pois, como adiantado, já foram as penas bases mantidas no mínimo legal." (TJSP; Apelação Criminal 1502696-32.2021.8.26.0540; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 06/07/2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravos regimentais no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravo regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, Dje, 15.06.2021).g.n

“A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal” (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

“No mais, quanto à atenuante da confissão espontânea, verifico que sua aplicação foi devidamente afastada, no caso, pelo Juízo sentenciante, “em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal”, tendo o Magistrado pontuado que “a confissão de quem foi preso em flagrante, com imensa quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos para a preparação dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos, tratando-se de fato prescindível para a condenação” (fl. 54). Nesse contexto, considerando que a confissão do Acusado não foi utilizada pelas instâncias ordinárias como reforço de fundamentação da condenação, não se aplica a Súmula n. 545 desta Corte Superior, segundo a qual “[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal” (HC n. 668.711, Ministra Laurita Vaz, Dje de 21/03/2022).

Não incide, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência.

Ainda na última etapa, incabível o pretendido reconhecimento do instituto da “delação premiada”, prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, para a incidência do referido instituto, os requisitos do mencionado artigo devem estar presentes cumulativamente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DELAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRETENSÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. REGIME FECHADO. QUANTUM DA PENA RECLUSIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a configuração da delação premiada (art. 41 da Lei de Drogas), é preciso o preenchimento cumulativo dos requisitos legais exigidos. Conforme consignaram as instâncias ordinárias, nenhuma colaboração foi prestada pelo Agravante no sentido de dados acerca do local e da pessoa que lhe forneceu os 21,70 kg de cocaína. 2. A elevação da pena-base foi adequadamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis que, de fato, emprestaram especial reprovabilidade à conduta do Acusado, mormente em se considerando a quantidade e qualidade do entorpecente apreendido. Por consequência, mantém-se o regime fechado (art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1301255/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, Dje 02/12/2013 – grifo nosso).

Na mesma linha o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (Artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO [...] DELAÇÃO PREMIADA - Inviável a redução da reprimenda pela aplicação da delação premiada, quando não preenchidos os requisitos

previstos no art. 41 da Lei n.º 11.343/06. [...] Anote-se que o art. 41 da nova lei de drogas menciona requisitos cumulativos para a aplicação da especial causa de diminuição e pela leitura do r. artigo, tem-se que é necessário que a colaboração possa ter efetividade para o desmantelamento de quadrilha ou bando criminoso, ou mesmo para a identificação de outro traficante, possibilitando que se possa oferecer denúncia e processamento do coautor. Desta feita, não há subsídios que apontem que a delação feita pelo apelante tenha se tornado objeto de investigação. Destaco que, no momento da abordagem, seu comparsa conseguiu fugir e o apelante em nada colaborou para sua identificação ou captura. (TJSP; Apelação Criminal 1500713-03.2018.8.26.0540; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019).

Na hipótese, não houve colaboração por parte do réu para a descoberta de eventual fornecedor ou outros colaboradores do narcotráfico. A mera indicação do local de armazenamento dos entorpecentes não é suficiente para o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena. Sobre o tema:

SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) [...] - DOSAGEM DAS PENAS EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO LEGAL, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS E DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 41 DO MESMO DIPLOMA LEGAL - REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO ADEQUADO À ESPÉCIE, MOSTRANDO-SE INADMISSÍVEL A CONCESSÃO DE QUAISQUER BENESSES - RECURSO DESPROVIDO. [...] Outrossim, no tocante ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, anoto que a situação verificada nos autos não se amolda ao referido dispositivo. Não se perca de vista que a ré, em juízo, alterou sua versão dos fatos e alegou que atuava apenas como 'olheira' do tráfico, não contribuindo em momento algum com a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, ausente, portanto, qualquer colaboração que permitisse desmantelar o grupo criminoso. Assim, nota-se que a ré apenas admitiu ao ser abordada o que foi constatado pela diligente ação policial e, pelo que se depreende dos relatos dos agentes públicos, indicou o barraco onde estava o restante das drogas e dinheiro pretendendo que com isso fosse 'liberada' pelos agentes públicos, não indicando sequer quem seria o proprietário do local (teria mencionado o nome de "Pamela" na fase de inquérito, porém não forneceu qualquer informação que permitisse a identificação de tal pessoa). [...] (TJSP; Apelação Criminal 1517865-93.2019.8.26.0228; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020 - grifo nosso).

SENTENÇA CONDENATÓRIA DO APELANTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT), [...] - APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS, ACENANDO COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, APLICANDO-SE DO REDUTOR LEGALMENTE PREVISTO NA FRAÇÃO MÁXIMA E A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS, COM IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), [...] INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 41 DO MESMO DIPLOMA LEGAL PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS [...] Outrossim, no tocante ao pedido de aplicação do instituto da delação, prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, anoto que a situação verificada nos autos não se amolda ao referido dispositivo, uma vez que o réu não colaborou com a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Em verdade, CARLOS afirmou que RICARDO seria mero usuário de entorpecentes, a despeito de o corréu ter admitido em sede policial que era responsável por transportar os entorpecentes (fl. 6), não se insurgindo o Ministério Público a respeito. Tampouco indicou quem seria a terceira pessoa que fugiu por ocasião da abordagem policial, não havendo, portanto, nenhuma colaboração que contribuísse para desmantelar o grupo criminoso. Ressaltando-se, ainda, que as

drogas foram localizadas na residência após os policiais sentirem forte odor de maconha vindo do local. [...] (TJSP; Apelação Criminal 0061634-17.2018.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020 - grifo nosso).

Define-se, assim, a condenação em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

O réu, reincidente, deverá cumprir pena sob regime penitenciário fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Pela mesma razão não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de concessão do sursis, insuficientes para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu PETERSON APARECIDO RIBEIRO DE SOUZA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 08 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 800 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denego ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas e dos objetos apreendidos (fls. 13-4), bem como a perda dos valores (fl. 77), em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita ao réu (fl. 141). Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA